

1500506-29.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...].

Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).

"Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500506-29.2022.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-29.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEX RODRIGO DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALEX RODRIGO DOS SANTOS e ESTEFÂNIA CARVALHAL imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 33, caput, em combinação com o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que no dia 10 de março de 2022, às 23h51min, na Praça São Benedito, Melo, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, nas imediações de estabelecimentos de ensino e hospitalar, bem como de entidades religiosas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, eles traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, peso líquido aproximado de 4,26 gramas de cocaína, divididos em dezoito porções, acondicionados em "ependorfs"; 4,24 gramas de cocaína, divididos em 45 porções, acondicionados em "ependorfs"; e 0,10 grama de cocaína, na forma de crack, em uma porção, sem autorização e em desacordo com determinação legal e Regulamentar.

Os fatos e as circunstâncias do crime foram expressa e minudentemente descritos na denúncia de fls. 153/155.

A denúncia, instruída com o inquérito policial, foi recebida em 14 de junho de 2022 pela decisão de fls. 165/167.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia às fls. 194/195 e 230.

Posteriormente foram citados.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e colhido o interrogatório dos réus (fls. 236/237).

As partes apresentaram oralmente as suas alegações finais.

Relatei. Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência policial (fls. 09/11), pelo auto de exibição ea apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 27/28), pelo laudo químico toxicológico (fls. 158/160) e pela prova oral colhida.

A autoria restou parcialmente esclarecida e só pode ser atribuída ao réu ALEX.

Na fase policial ele permaneceu em silêncio (fl. 05) e em juízo compareceu para negar a traficância afirmando-se mero usuário de entorpecentes. Disse que é usuário de cocaína e que usava a droga sem o conhecimento da esposa, a ré ESTEFÂNIA.

Afirmou que três dias antes da prisão havia recebido R\$ 950,00 da sua empregadora Cargil e com a ré veio para Barretos, onde se hospedaram em um hotel. No dia dos fatos ela pediu para sair e comer um lanche e ambos foram até a praça em frente ao hotel. Ele pediu que ela fosse na frente e se dirigiu até o banheiro da praça, onde adquiriu 18 pinos de cocaína para o seu consumo próprio. Comprou tal quantidade de drogas para não precisar ficar voltando ao ponto de tráfico várias vezes. Alegou que voltou até a ré, momento em que avistou a aproximação dos policiais, razão pela qual jogou a sacola com as drogas no chão. Ambos foram abordados e revistados. Estefânia foi separada dele e ele, ao ser questionado, confessou a posse dessas drogas e afirmou que as consumiria. Disse que não havia mais entorpecentes no quarto em que estava com a ré e que o dinheiro apreendido era o restante do seu pagamento e serviria para pagar a estadia de ambos no imóvel.

ESTEFÂNIA declarou o quanto segue à autoridade policial, in verbis:

"Acerca dos fatos esclarece que em dezembro do ano passado conheceu Alex através da rede social. Passou a encontrar-se com ele no início deste ano e faz cerca de um mês passaram a morar juntos na casa da mãe dele. Faz três dias que vieram para Barretos com intenção de arrumarem emprego e estavam hospedados na Pensão Viajantes, próximo à estação rodoviária. Hoje à noite, foram até a praça para comprarem um lanche. Estava conversando com uma moça quando os policiais chegaram. Nesse momento, Alex aproximou-se e abraçou a interroganda. Foram abordados pelos policiais. Não viu Alex dispensar nenhuma sacola. Acompanhou os policiais até o quarto na pensão, sendo que um dos policiais mostrou à interroganda vários pinos com cocaína e falou que tinha encontrado no quarto. Não viu os policiais encontrarem os pinos. Não tinha conhecimento que esses pinos estavam no quarto. Ontem escutou Alex conversando com um rapaz em frente da pensão e ouviu ele dizer que vendia cada pino a dez reais, mas não chegou a ver nenhuma droga. Não usa nem vende drogas. Sua família reside na cidade de Terra Roxa. Tem um filho de oito anos que mora com a interroganda, sua mãe e sua irmã. Atualmente não está trabalhando. Já tentou separar-se de Alex e ir embora para sua casa, mas ele não permitiu e agrediu a interroganda" (fl. 06).

Em juízo, entretanto, apresentou versão um tanto quanto divergente, claramente com a intenção de eximir seu marido da responsabilização criminal.

Na oportunidade ela afirmou que veio com o réu ALEX para Barretos três dias antes da prisão e na ocasião havia saído para comerem um lanche na praça em frente ao imóvel. Alegou que pediram os lanches e foram informadas que eles ficariam prontos em trinta minutos. Nesse período o réu foi até o banheiro e logo depois que voltou chegaram os policiais e os abordaram. Disse que não viu ALEX dispensando no chão uma sacola com drogas. Os policiais a algemaram nas mãos e nos pés e a levaram até o hotel em frente porque haviam encontrado no bolso de ALEX uma chave com a identificação do quarto de ambos. Negou ter autorizado a entrada dos milicianos no quarto, mas que mesmo assim eles ingressaram e o revistaram. Nada de ilícito foi localizado no quarto. Alegou que pouco depois chegaram dois outros policiais e disseram que encontraram uma sacola com drogas pendurada em um cabide que segurava as toalhas do hotel. Disse, entretanto, que não viu a sacola sendo aberta e nem

tampouco as drogas que se afirmou terem sido encontradas. Questionada pela Douta Defesa, afirmou que os policiais foram até o hotel não só porque encontraram a chave do quarto, mas também porque lhe disseram que a denúncia que receberam informava o local em que eles estavam hospedados.

Os policiais que atuaram na diligência que resultou na prisão dos réus confirmaram em juízo o que antes já haviam declarado à autoridade policial e esclareceram a verdadeira dinâmica dos fatos.

O policial Marcos Vinicius Barbosa relatou em juízo que na data dos fatos houve uma denúncia via 190 informando que um casal, cujas características e vestes foram informadas, estava na praça indicada a praticar o tráfico de drogas e que eles dormiam no Hotel dos Viajantes, razão pela qual resolveu apurá-la com seu companheiro de farda. Disse que ao se aproximarem da praça avistara o casal com as mesmas características e que esses, ao vê-los, mudaram de direção. ALEX também abraçou ESTEFÂNIA e jogou uma sacola plástica no chão. Ambos foram abordados e revistados. Com o réu foram encontrados R\$ 52,00 em dinheiro, um aparelho de telefonia celular, uma chave e uma gilete. A ré não tinha nada de ilícito consigo. Questionado, ALEX negou a traficância. Na sequência ESTEFÂNIA foi questionada e informou que ambos estavam hospedados no hotel referido, indicou aos milicianos o quarto em que estavam e autorizou a entrada deles. O quarto de nº 8 foi revistado e nele encontrados, sobre a cama, 45 pinos de cocaína, uma pedra de crack e, dentro dos bolsos de roupas existentes, a quantia de R\$ 377,00. Questionada, a ré afirmou que sabia que ALEX vendia drogas e que já havia ouvido ele as comercializando por R\$ 10,00 cada porção de cocaína e as porções de crack por valores diversos a depender do tamanho.

Em sentido praticamente idêntico foram as declarações do policial Daniel Mattos de Carvalho. Esse miliciano participou da mesma diligência e confirmou a sua dinâmica. Confirmou que foi o responsável pela revista no réu ALEX e a apreensão com ele dos bens já discriminados. Confirmou a dispensa por ele da sacola no interior da qual havia 18 porções de cocaína, bem como que a ré indicou o número do quarto em que estava hospedada com o réu ALEX e autorizou a entrada deles no imóvel, onde foram encontradas as demais drogas e o dinheiro anteriormente discriminados.

De forma diversa de seu companheiro de farda, entretanto, afirmou que a denúncia que os levou ao local da prisão dos réus informava apenas que o homem identificado pelas características e vestimentas era o traficante, não obstante ele estivesse acompanhado de uma mulher. Nada dizia, entretanto, sobre a efetiva participação da mulher no referido crime.

Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.

Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator:

Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).

"Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017).

Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais tivessem alguma razão para levemente incriminarem os réus, imputando-lhes a prática de crime do qual os sabiam inocentes.

Num primeiro momento há de se afastar a tese defensiva de nulidade probatória decorrente de suposta invasão de domicílio, esse considerado na hipótese como o hotel em que estavam hospedados os réus.

Não obstante vozes em sentido contrário em decisões sem efeito vinculante, continuo convencido de que a legislação não exige apresentação de mandado judicial para ingresso em residência sem autorização do morador nas hipóteses de crime permanente, caso dos autos.

Em caso parelho ao ora analisado decidiu o 7º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo voto condutor do Desembargador Moreira da Silva, seguido à unanimidade por seus ilustres pares:

"Não há falar-se em nulidade do processo sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, sobretudo porque a referida inviolabilidade comporta exceção justamente quando existe um crime em andamento no interior de residência, como é o caso dos autos, em que avulta a hipótese de flagrante delito (CF, art. 5º, inc. XI, e CP, 150, § 3º, inc. II) (Revisão Criminal nº 0012798-71.2015.8.26.0000, DJ. 14.02.2019).

Colhe-se do referido acórdão julgado do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CRIME PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 6.

Recurso ordinário em habeas corpus improvido" RHC 86082 / RS - RIO GRANDE DO SUL - RECURSO EM HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 05/08/2008 - Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008).

Esse é o caso dos autos, como mais adiante se destacará.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que apenas se existirem indícios de tráfico é que o ingresso no imóvel estará autorizada sem a apresentação de mandado judicial.

No caso dos autos tais indícios sobejam. Os policiais ouvidos em juízo, sobre os quais não pende qualquer suspeita de parcialidade, afirmaram em uníssono que a polícia militar já vinha recebendo informações da prática do tráfico de drogas na praça em que ocorreu a prisão. Marcos Vinícius informou que as denúncias indicavam um casal de traficantes e Daniel informou que em verdade o homem apenas era indicado como sendo o criminoso.

Na data dos fatos nova denúncia chegou pelo telefone 190 e foi apurada. Os réus foram vistos com as mesmas vestimentas informadas e no mesmo local dos fatos. Ao vê-los se aproximando eles mudaram a direção pela qual caminhavam, o que indica medo, e ALEX dispensou no chão, antes da abordagem, uma sacola que tinha em seu interior 18 pinos de cocaína.

A referida quantidade não é condizente com a alegação de posse para uso próprio, mormente se considerarmos a baixa capacidade financeira do réu. Não se mostra crível a alegação dele em interrogatório, repetida constantemente em processos de tráfico, de que adquirira tantas porções de cocaína para não ser obrigado a voltar ao ponto de tráfico, pois esse, se realmente existisse no local por ele informado - um banheiro da praça - ficaria exatamente na frente do hotel em que ele estava hospedado, o que facilitaria seu retorno quantas vezes fossem necessárias.

Não se pode deixar de considerar que o réu ALEX é reincidente específico no tráfico de drogas e não um suposto usuário qualquer, que teme transitar onde o crime é praticado.

Pois bem.

A localização das drogas após dispensa por um indivíduo que vinha sendo apontado como traficante, no exato local da denúncia, configurava indícios sobrados da prática do tráfico.

Com ALEX havia também uma chave que se descobriu fosse do quarto em que ele e a ré estavam hospedados. Nessa questão específica é importante ressaltar que a própria ré ESTEFÂNIA declarou em seu interrogatório judicial que os policiais foram até o hotel não só porque encontraram a chave do quarto, mas também porque lhe disseram que a denúncia que receberam informava o local em que eles estavam hospedados, o que também corrobora a versão por eles apresentada.

Evidente, portanto, que diante de indícios claros e concretos da prática do tráfico os policiais estavam autorizados a ingressar no quarto que hospedava os réus sem mandado judicial e até mesmo sem autorização de qualquer um deles.

Pouco importa, portanto, se houve ou não autorização de ESTEFÂNIA para isso. A prova dos autos é válida.

E mesmo que diferente fosse eventual nulidade atingiria apenas a apreensão de drogas no interior do quarto e não aquela realizada fora dele, após a dispensa pelo réu ALEX, que já confirmaria de forma concreta a prática do crime.

Prossigo.

ALEX não dispunha de apenas dezoito pinos de cocaína. No interior do quarto em que ele e a ré estavam havia pelo menos três dias de acordo com relatos deles próprios, foram encontrados mais 45 pinos de cocaína e uma outra porção de crack passível de fracionamento. Não se produziu nos autos indício mínimo de prova, e esse ônus era da Doute Defesa, de que esses entorpecentes tenham sido "plantados" no local pelos policiais que atuaram na diligência.

Se eles estavam no quarto, se o réu ALEX vinha sendo indicado em denúncias como traficante e se ele foi visto por policiais e confessou ter jogado no chão uma sacola com outras 18 porções de um dos entorpecentes, certo é que tudo lhe pertencia.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento, aliadas à comprovação da

denúncia recebida pelos policiais, deixam clara a destinação de tudo ao tráfico, de modo que não há espaço para a desclassificação pretendida.

Os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório afirmaram que as drogas do quarto estavam sobre a cama, de modo que não seria possível que as pessoas que nele estivessem desconhecem sua existência. O fato é crível, até mesmo diante da categoria do hotel em questão, de viajantes de baixa renda.

É bem possível, senão certo, que a ré ESTEFÂNIA tivesse conhecimento das drogas que ALEX mantinha no quarto de hotel. Não há provas seguras, entretanto, de que ela estivesse em conluio com ele para a prática do crime de tráfico de drogas. Nada nos autos indica que os entorpecentes fossem também dela. Não se produziu indício mínimo de prova de que ela tenha comercializado alguma porção de entorpecente no período em que esteve no hotel. Não ficou claro nos autos se a denúncia recebida pelos policiais indicava um casal de traficantes ou apenas o homem, pois cada policial informou-a de uma jeito.

Somente o fato de estar no mesmo ambiente que um traficante não torna o seu acompanhante também criminoso, pois o que configura o delito é a prática efetiva de um dos vários verbos do tipo penal. Nenhum deles se comprovou tenha a ré praticado. É possível que ela estivesse também imbuída do mesmo propósito de seu companheiro? Evidente que sim. Ocorre que o Direito Penal não se contenta com possibilidades, mas sim com certeza, senão absoluta, pelo menos aquela que afaste as dúvidas razoáveis. E essas permanecem no caso dos autos, pois também há possibilidade de que ESTEFÂNIA apenas soubesse do tráfico de ALEX e não o auxiliasse na empreitada criminosa.

Não se pode deixar de destacar que na fase policial ela declarou, e os policiais ouvidos em juízo afiançaram, que vinha sendo mantida em cárcere privado pelo réu ALEX, impedida de deixar o hotel e voltar para a sua cidade de origem. Sendo isso verdade, o que ela negou em interrogatório judicial, estaria a ré sob coação que lhe retiraria a voluntariedade dos atos e, portanto, o próprio dolo.

Diante dessa conjuntura melhor é que se aplique o princípio in dubio pro reo para absolver ESTEFÂNIA.

Passo à dosimetria da pena de ALEX.

Não obstante a diversidade dos entorpecentes apreendidos, ambos com alto poder destrutivo, reputo que a quantidade deles não autoriza por si só o recrudesimento da pena base com fundamento no art. 42 da lei de drogas. As demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não desfavorecem o réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase aumento a pena em 1/4 em razão da reincidência específica de ALEX, comprovada pela condenação definitiva que lhe foi imposta nos autos do processo criminal nº 0002219-84.2013 (fl. 54).

Na terceira fase deixo de aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é reincidente específico, e aumento a reprimenda em 1/6 em razão da comprovação da configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.

O relatório de investigações e respectivo croqui de fls. 125/126 comprova que o crime vinha sendo praticado pelo réu entre 50 e 100 metros da Escola Municipal Luiza Parassu Borges, o que já é suficiente para majorar a pena, pois nos termos do entendimento jurisprudencial já sufragado no Superior Tribunal de Justiça

"O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...]. IV - A simples prática do tráfico de drogas

na proximidade de tais estabelecimentos é suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" - destaquei - (STJ - AgRg no AREsp: 1028605 SP 2016/0327378-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018).

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do

delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no RESp 1.349.357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014).

É importante destacar que a majoração se impõe independentemente da escola estar aberta no momento da prisão em flagrante de ALEX, pois a prova dos autos é segura, até mesmo diante das declarações dele e da ré, de que ambos estavam hospedados na cidade havia três dias, período em que certamente o primeiro vinha se dedicando ao tráfico em horários diversos, inclusive nos de funcionamento do aparelho municipal. Não havendo outras causas tendentes à modificação da pena, concretizo-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, em razão da extrema gravidade do delito praticado e a da reincidência específica do réu.

Em caso parêlho ao ora julgado decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado:

"O regime fechado impõe-se. Observo que foi apreendida considerável quantidade e variedade de entorpecentes. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico. No caso, a natureza da droga apreendida (cocaína) também indica maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente possui grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Além disso, o réu é reincidente o que indica a necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime. Portanto, demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal" (TJSP, Apelação nº 0032250-24.2011.8.26.0577, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, DJ. 20.03.2014). Deixo de aplicar ao caso o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, para considerar o período de pena provisória cumprida pelo réu na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Filio-me ao entendimento jurisprudencial, que não se pode considerar minoritário, de que a detração pretendida tem como única finalidade conceder a progressão de pena ao condenado sem a análise dos dois requisitos legais necessários para que se a defira. Não se nega que detração e progressão de regime são institutos diversos, mas na hipótese do art. 387, § 2º, do CPP, a única consequência esperada é a fixação de um regime menos gravoso de pena em razão da consideração do período de prisão provisória já cumprido pelo condenado. Fosse detração pura e simples e a própria pena deveria ser reduzida em razão dessa consideração, o que, é cediço, não ocorre.

Como bem ponderou a Desembargadora Fátima Gomes, no julgamento da Apelação Criminal nº 0079918-73.2018.8.26.0050, "a inovação normativa inserida pela Lei nº 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime prisional" (TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJ. 23/01/2020).

No mesmo sentido é o entendimento do Desembargador Farto Sales, in verbis:

"Tampouco há se cogitar de mitigação do tratamento penitenciário com fulcro no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, mormente porque a matéria relativa à detração não comporta discussão aprofundada no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais, regra não contrariada pela

alteração legislativa promovida pela Lei nº. 12.736/12.

Diga-se, também, que, para a progressão de regime, necessária, ainda, a presença do requisito subjetivo, cuja apreciação deve ocorrer no momento executório, sendo a matéria relativa ao merecimento do preso nitidamente estranha à fase cognitiva" (TJSP, Apelação Criminal nº 0106392-18.2017.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, DJ. 06.02/2020).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER ESTEFÂNIA CARVALHAL, filha de Edson de Jesus Carvalhal e Rosemeire Benedita dos Santos, portadora do RG nº 56.836.730, da imputação que lhe é irrogada na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e para CONDENAR ALEX RODRIGO DOS SANTOS, filho de Antonio Carlos dos Santos e Luzia Alves da Silva dos Santos, portador do RG nº 49.594.974, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, em combinação com o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O réu ALEX, reincidente específico, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República.

Declaro perdida em favor da UNIÃO a quantia em dinheiro apreendida nos autos, pois seguramente é proveniente do tráfico. Após o trânsito em julgado providencie-se a sua reversão para o FUNAD. Por não ter se produzido nos autos prova de que o aparelho celular apreendido vinha sendo utilizado para a prática do crime defiro a sua restituição ao réu, após o trânsito em julgado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Revogo as medidas cautelares impostas à ré ESTEFÂNIA na decisão de fls. 88/90.

Publique-se e intime-se.

Barretos, 17 de agosto de 2022.

Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA